# DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

**NRO. DE EXPEDIENTE** : EXP. NRO. 24-2022-CEAS-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

**MODALIDAD DE ARBITRAJE** : Arbitraje de Emergencia.

**PARTES INTERVINIENTES** :

**Demandante** : Consorcio Doce Corrales.

**Demandado** : Gobierno Regional de Ayacucho.

**ARBITRO DE EMERGENCIA** : Abg. Carlos Enrique Álvarez Solís.

**SECRETARIA ARBITRAL** : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

**PEDIDO CAUTELAR** : Medida Cautelar de No Innovar

**INICIO DE LA SOLICITUD** : 26 de diciembre de 2022.

**FECHA DE CONCLUSION** : 03 de enero de 2023.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Trujillo, 03 de enero de 2023

**RESOLUCIÓN DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA N°02**

**VISTOS:**

**(i)** El escrito sumillado como "***Solicitamos medida cautelar fuera del proceso***" presentado por el Consorcio Doce Corrales.

**(ii)** Carta N°107-2022/CD-RC con asunto "***Remito voucher de pago por Recibo por Honorarios Arbitrales y Gastos Administrativos***" presentado por el Consorcio Doce Corrales.

**CONSIDERANDO:**

**A.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE HONORARIOS ARBITRALES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSORCIO DOCE CORRALES.**

**1.** Mediante la Carta N°304-2022 del presente expediente de arbitraje de emergencia, se fijó la liquidación de gastos arbitrales a asumir por parte del Consorcio Doce Corrales, en el plazo de dos (02) días hábiles, según se señaló en la citada misiva.

**2.** A través del documento de vistos (ii) el Consorcio Doce Corrales, en calidad de peticionante de la medida cautelar de emergencia, acreditó el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos que corresponden.

**3.** Por lo que, corresponde tener por cumplidos los gastos indicados y, en consecuencia, proceder al análisis de la medida cautelar solicitada por el Consorcio Doce Corrales.

**B.- SOBRE LA ABSOLUCIÓN DE LA ENTIDAD Y REALIZACIÓN DE AUDIENCIA ESPECIAL EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ARBITRAL.**

**4.** A través de la Resolución de Arbitraje de Emergencia N°01 de fecha 26 de diciembre de 2022, el Árbitro de Emergencia precisó que posteriormente con la absolución de la Entidad se procedería a la realización de una Audiencia Especial, según se lee:

> ***QUINTO*: PRECISAR** *que, posteriormente al plazo concedido por el Árbitro de Emergencia, con o sin la absolución de la Entidad, se citará a ambas partes a la realización de una audiencia especial para discutir la medida cautelar, según se considere pertinente.*

**5.** Que, empero, a la fecha no se tiene conocimiento de la absolución del Gobierno Regional de Ayacucho sobre el particular, por lo que mediante la presente Resolución se deja constancia de dicha situación.

**6.** Por tanto, dado cuenta que no se ha ejercido el derecho de defensa por la entidad y no se cuenta con contradicción respecto de la medida cautelar solicitada por el Consorcio Doce Corrales, el Árbitro de Emergencia considera pertinente prescindir de la realización de Audiencia Especial y procede a resolver el pedido cautelar del contratista en el sentido expuesto a continuación.

## C.- GENERALIDADES SOBRE EL ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

**7.** El Arbitraje de Emergencia es un mecanismo del proceso arbitral que *tiene como finalidad la dación de medidas de emergencia previas a la interposición de una solicitud arbitral, es decir, con anterioridad al proceso arbitral, a efectos de garantizar la eficacia del laudo final o tutelar el derecho la parte solicitante*. Asimismo, las medidas que pueden solicitarse en esta vía con las llamadas medidas cautelares, mismas que se encuentran contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente, aquellas descritas por el artículo 47° del Decreto Legislativo N°1071 – Decreto Legislativo que regula el arbitraje en el Perú (en adelante, Ley de Arbitraje).

**8.** Asimismo, una medida de emergencia es aquella que ordena el Tribunal Arbitral previamente al inicio del arbitraje, a efectos de asegurar la eficacia de la decisión proveniente del Laudo Arbitral o evitar que por el solo paso del tiempo del proceso se genere un daño irreversible que afecte directamente a quien le corresponde el derecho. No obstante, estas medidas son, por naturaleza, temporales y *su continuidad están sujetas a que el solicitante interponga la Solicitud Arbitral en el plazo concedido por el Tribunal Arbitral*.

**9.** Asimismo, bajo el amparo de lo señalado y conforme a su derecho, mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2022, el Consorcio Doce Corrales interpone el pedido de medida de emergencia mediante el escrito de vistos (i) ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, contra el Gobierno Regional de Ayacucho, en virtud del Contrato N°008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-O APFF para la contratación de la ejecución de la Obra: "*Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal – 34.5 Km EMP. AY-647 (Tranca) – AY-646 (Sayhua – Doce Corrales) del distrito de Soras y San Pedro de Larcay, Provincia de Sucre, Región Ayacucho*", suscrito por ambas partes el 17 de febrero de 2021; solicitando se dicte una medida cautelar de no innovar consistente en ordenar al Gobierno Regional de Ayacucho se abstenga de ejecutar:

**(i)** La **CARTA FIANZA N°E0359-03-2021**, emitida por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, por el importe de S/. 767,455.80 (setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 80/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N°008-2021-GRASEDE CENTRAL-OAPF; y sus futuras renovaciones.

**(ii)** Solicitamos además que los efectos de la orden cautelar se extiendan a SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, con domicilio en la Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, Edificio "Real Diez", Ofi. 601 Centro Empresarial Real – Lima; **ORDENANDO** se abstenga y/o rechace cualquier requerimiento y/o solicitud por parte del GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO destinada a ejecutar La **CARTA FIANZA N° E0359-03-2021**.

En consecuencia, se curse comunicación al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, con domicilio en el Jr. Callao N°122 – Ayacucho – Huamanga - Ayacucho; así como a SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS con sede en la Av. Víctor Andrés Belaunde N°147, Edificio "Real Diez", Ofi. 601 Centro Empresarial Real – Lima.

**10.** Según el literal b) del numeral 1, del artículo 47° de la Ley de Arbitraje, se indica como medida cautelar, que puede entenderse como una de no innovar, que el Tribunal Arbitral ordene a una de las partes: "*Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral*" [Subrayado agregado]. Es decir, tienen como finalidad evitar que no se modifique la situación de las cosas hasta que pueda emitirse el Laudo Arbitral o, en su defecto, hasta que desaparezca el peligro.

**11.** La teoría cautelar reconoce tres presupuestos para la adopción de medidas cautelares, mismos que deberán ser materia de análisis por el Árbitro de Emergencia en la presente Resolución, estos requisitos son los siguientes: **i)** La **verosimilitud del derecho** (*fumus boni iuris*); **ii)** El **peligro en la demora** (*periculum in mora*); y, **iii)** La **razonabilidad o adecuación de la medida**. Por otro lado, la doctrina y la legislación peruana reconocen a la contracautela como un requisito adicional para la adopción de medidas cautelares, así se reconoce en el numeral 4, del artículo 610° del Código Procesal Civil, y en el numeral 1, del artículo 47° de la Ley de Arbitraje.

**12.** No obstante, previamente a dicho análisis y de acuerdo con el artículo 9° de las Reglas de Árbitro de Emergencia[1], corresponde al Árbitro de Emergencia

[1] Anexo I del Reglamento de Arbitraje del CECARD: https://cecard.org/wp-content/uploads/2022/10/REGLAMENTO-DE-ARBITRAJE-CECARD-10-2022.pdf.

pronunciarse sobre la *admisibilidad de la solicitud* y su *competencia* para ordenar la Medida de Emergencia, así como las *razones de su decisión.*

## D.- RESPECTO DE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

**13.** El artículo 1° de las Reglas de Árbitro de Emergencia regula los requisitos que debe cumplir la Solicitud, según el siguiente detalle:

> ***Artículo 1°. -***
> ***Solicitud***
> *(…)*
> *2. La Solicitud de medidas de emergencia debe contener:*
> *a. La información de contacto de las partes y de sus representantes.*
> *b. La medida cautelar o provisional que se solicita.*
> *c. La razón o las razones por las cuales el solicitante requiere que se dicte medidas cautelares urgentes.*
> *d. Una descripción breve de la controversia sometida o que ha de ser sometida a arbitraje.*
> *e. Una copia del convenio arbitral sobre cuya base se ha de resolver la controversia y del contrato del cual deriva dicha controversia.*

**14.** Para efectos de corroborar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en las Reglas de Árbitro de Emergencia, se procede al análisis comparativo entre los requisitos y el escrito de Solicitud del Reglamento en los siguientes términos:

**a) La información de contacto de las partes y de sus representantes.**

**Datos de la parte solicitante:**

> **CONSORCIO DOCE CORRALES** (integrado por MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C., con RUC N° 20494336112, con domicilio legal en el Jr. Juan Scarsi N° 224 Primer Piso – Ayacucho – Huamanga – Ayacucho; y MIFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L., con domicilio legal en el Jr. Lima N° 437 Int. 02 – Ayacucho – Huamanga – Ayacucho), con RUC N° 20494336112 (de su operador tributario), con domicilio legal en el Jr. Juan Scarsi N° 224 Primer Piso – Ayacucho – Huamanga – Ayacucho, con correo electrónico voriundo@minkasac.com y lauragalvanpamela@gmail.com; debidamente representado por **VLADIMIR HERBER ORIUNDO OCHOA**, identificado con DNI N° 28314310; antes usted nos presentamos y decimos:

**Datos de la Entidad:**

**1. PARTE DEMANDADA**

Siendo que la petición cautelar tiene una naturaleza extra procesal, la futura demanda será dirigida en contra del **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO** con RUC N° 20452393493, con domicilio legal en el Jr. Callao N° 122 – Ayacucho – Huamanga – Ayacucho; debidamente representado por su Gerente General Wilhelm Gilberto Oré Chipana, identificado con DNI N° 28284370.

**b) La medida cautelar o provisional que se solicita.**

**3. PRETENSIÓN CAUTELAR**

En ejercicio del derecho a la tutela cautelar, y en salvaguarda de los derechos e intereses del CONSORCIO DOCE CORRALES; al amparo de lo dispuesto en el artículo 687° del Código Procesal Civil, del inciso b) del artículo 63° del Reglamento de Arbitrare de Centro de Arbitraje - CECARD y el artículo 47° del Decretos Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 1071; **SOLICITAMOS DICTE MEDIDA CAUTELAR de NO INNOVAR CONSISTENTE EN: ORDENAR** al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO **SE ABSTENGA A EJECUTAR**:

(i) La **CARTA FIANZA N° E0359-03-2021**, emitida por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, por el importe de S/. 767,455.80 (setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 80/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N° 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF; y sus futuras renovaciones.

(ii) Solicitamos además que los efectos de la orden cautelar se extiendan a SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, con domicilio en la Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, Edificio "Real Diez", Ofic. 601 Centro Empresarial Real – Lima; **ORDENANDO** se abstenga y/o rechace cualquier

requerimiento y/o solicitud por parte del GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO destinada a ejecutar La **CARTA FIANZA N° E0359-03-2021**.

En consecuencia, se curse comunicación al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, con domicilio en el Jr. Callao N° 122 – Ayacucho – Huamanga - Ayacucho; así como a SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS con sede en la Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, Edificio "Real Diez", Ofic. 601 Centro Empresarial Real – Lima.

**c) La razón o las razones por las cuales el solicitante requiere que se dicte medidas cautelares urgentes.**

**8. FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN CAUTELAR**

**Antecedentes**

8.1. Con fecha 17 de febrero de 2021 el CONSORCIO DOCE CORRALES (integrado por MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.; y MIFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L.), debidamente representado por VLADIMIR HERBER ORIUNDO OCHOA; y el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO debidamente representado por su Gerente General WILHELM GILBERTO ORÉ CHIPANA, suscribieron el CONTRATO N° 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF (en adelante el CONTRATO), que tiene como objeto la ejecución de la obra "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – 34.5 KM EMP. AY-647 (TRANCA) – AY-646 (SUYHUA-DOCECORRALES) DEL DISTRITO DE SORAS Y SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO".

**d) Una descripción breve de la controversia sometida o que ha de ser sometida a arbitraje.**

**6. PRETENSIONES DE LA FUTURA DEMANDA ARBITRAL**

Siendo que, la petición cautelar invocada tiene una naturaleza extra procesal, y además, en nuestro sistema jurídico las medidas cautelares tienen un carácter instrumental; es necesario señalar que se iniciara un proceso arbitral que tendrá como objeto las siguientes pretensiones:

**6.1. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL**

Que el Tribunal Arbitral **DECLARE LA INEFICACIA** de la Resolución del Contrato N° 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, efectuada por el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, comunicada mediante Carta Notarial N° 296-2022-GRA/GR-GG de fecha 06 de diciembre de 2022.

**6.2. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL**

Que el Tribunal Arbitral **ORDENE** al Gobierno Regional de Ayacucho asumir los gastos que irrogue la organización y tramitación del arbitraje, incluyendo los honorarios arbitrales, gastos administrativos, así como la asesoría técnica y legal.

**e) Una copia del convenio arbitral sobre cuya base se ha de resolver la controversia y del contrato del cual deriva dicha controversia.**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 018

De acuerdo con lo establecido en artículo del 96° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes,

De manera excepcional, las partes podrán resolver sus controversias mediante arbitraje ad hoc solo en los supuestos previstos en el Reglamento.

Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliación y/o arbitraje.

**15.** En ese sentido, debe declararse que la Solicitud de Medida de Emergencia presentada por el Consorcio Doce Corrales cumple con todos los requisitos

consignados en el artículo 1° de las Reglas de Árbitro de Emergencia del Centro de Arbitraje.

**E.- RESPECTO DE LA COMPETENCIA DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA PARA CONOCER LA MEDIDA DE EMERGENCIA SOLICITADA POR EL CONSORCIO DOCE CORRALES.**

**16.** En virtud de la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS del Contrato bajo análisis, las partes suscriben el convenio arbitral en los siguientes términos:

> CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 01
>
> De acuerdo con lo establecido en artículo del 96° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional según el acuerdo de las partes,
>
> De manera excepcional, las partes podrán resolver sus controversias mediante arbitraje ad hoc solo en los supuestos previstos en el Reglamento.
>
> Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliación y/o arbitraje.

**17.** Sobre el particular, se advierte que las partes han acordado que el tipo de arbitraje es institucional, empero no han señalado la institución arbitral que administrará el arbitraje, por lo que, en aplicación del literal b), del numeral 4 del artículo 99° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM – Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; el arbitraje deberá iniciarse en cualquier institución arbitral ubicada en el lugar de perfeccionamiento del contrato, según se lee:

> ***Artículo 99°. - Convenio arbitral***
> *(…)*
> *99.4. En los siguientes supuestos, el arbitraje deberá ser iniciado ante cualquier institución arbitral registrada y acreditada ante el OSCE ubicada en el lugar del perfeccionamiento del contrato o, en caso no exista una en dicho lugar, ante cualquier otra ubicada en un lugar distinto:*
> *(…)*
> *b) Cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional no se ha designado a una institución arbitral determinada.*

**18.** A su vez, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, es una institución arbitral ubicada en la ciudad de Ayacucho, donde se perfeccionó el contrato, según se puede apreciar del Registro Nacional de Árbitros y de Centros

de Arbitraje – RENACE del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, según se puede apreciar a continuación:

**LUGAR DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Ayacucho, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2021.

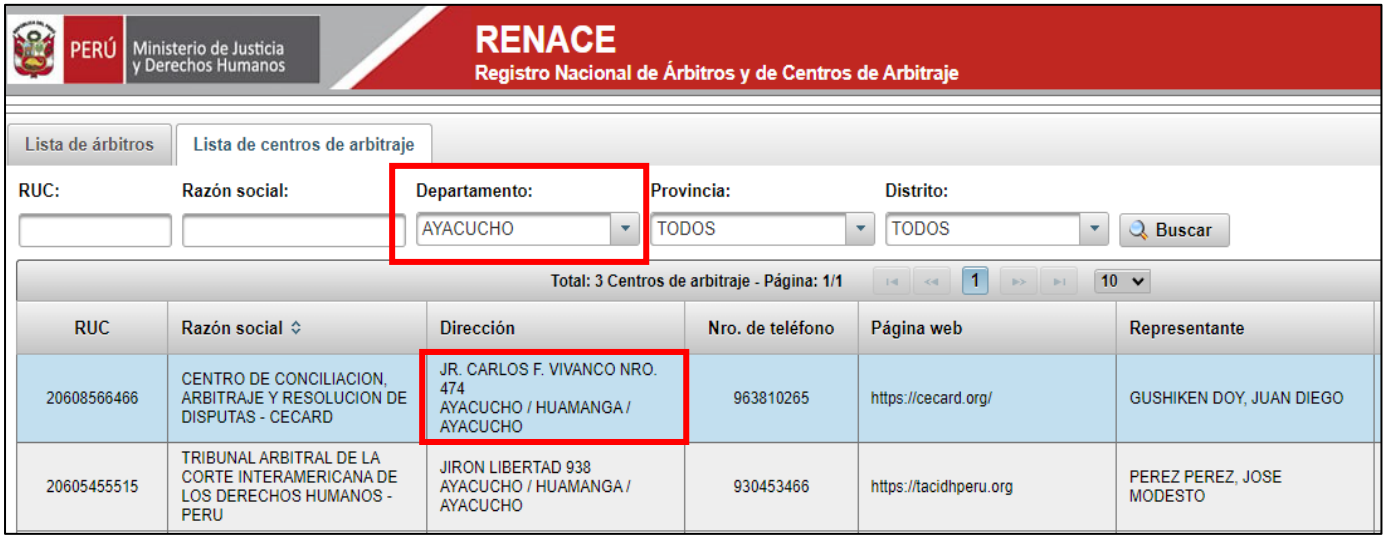
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA GENERAL

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO BOCECORRALES
Vladimir Herber Oriundo Ochoa
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"

**LUGAR DE REGISTRO DEL CENTRO DE ARBITRAJE EN EL RENACE**



PERÚ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

RENACE
Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje

Lista de árbitros | Lista de centros de arbitraje

RUC: | Razón social: | Departamento: AYACUCHO | Provincia: TODOS | Distrito: TODOS | Buscar

Total: 3 Centros de arbitraje - Página: 1/1

| RUC | Razón social | Dirección | Nro. de teléfono | Página web | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 20608566466 | CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y RESOLUCION DE DISPUTAS - CECARD | JR. CARLOS F. VIVANCO NRO. 474 AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO | 963810265 | https://cecard.org/ | GUSHIKEN DOY, JUAN DIEGO |
| 20605455515 | TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS - PERU | JIRON LIBERTAD 938 AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO | 930453466 | https://tacidhperu.org | PEREZ PEREZ, JOSE MODESTO |

**19.** Por tanto, es correcto señalar que el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD tiene plena competencia para administrar el arbitraje, de conformidad con lo señalado por el citado dispositivo legal.

**20.** Se precisa que la norma invocada anteriormente es concordante con la ley general aplicable supletoriamente, es decir, con el literal b) del numeral 2 del artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual dispone lo que sigue:

> ***Artículo 226°. - Convenio arbitral***
> *226.2. En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral: (…)*
> *b) Cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional no se ha designado a una institución arbitral determinada.*

**21.** A su vez, la institución arbitral referida contempla el arbitraje de emergencia como parte de los servicios a los que pueden acceder las partes del arbitraje por su solo sometimiento a los reglamentos del mismo, según se desprende del artículo 63° de su Reglamento de Arbitraje:

> ***Artículo 63º.-***
> ***Medida Cautelar emitida por Árbitro de Emergencia***
> *1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medidas cautelares urgentes puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud.*
> *2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora.*
> *3. Se extingue la competencia del Árbitro de Emergencia por la constitución del Tribunal Arbitral.*
> *4. El derecho de las partes de recurrir a un Árbitro de Emergencia no impide que cualquiera de ellas pueda solicitar a la autoridad judicial competente que dicte medidas cautelares.*

**22.** En ese sentido, es competencia del Consejo del Centro de Arbitraje la designación del Árbitro de Emergencia, según se puede leer del numeral 1, del artículo 3° de las Reglas de Árbitro de Emergencia:

> ***Artículo 3º.-***
> ***Nombramiento***
> *1. El Consejo nombra a un Árbitro de Emergencia seleccionado entre los que integran el Registro de Árbitros del Centro en el plazo de un (01) día luego de la recepción de la solicitud.*

**23.** En ese sentido, el Consejo Superior de Arbitraje designó a **CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SOLIS** como Árbitro de Emergencia para el presente proceso, mismo que se encuentra adscrito a la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje, según se aprecia[2]:

Ver en la página siguiente…

[2] Puede consultarse la nómina de árbitros de la institución arbitral en el portal web oficial de esta: https://cecard.org/arbitraje/.

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD

NÓMINA DE **ÁRBITROS**

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Álvarez Solis, Carlos Enrique. | RNA – OSCE |
| 02. | Apaza Moncada, Carol Yanely. | RNA – OSCE |
| 03. | Becerra Farfán, María Hilda. | RNA – OSCE |
| 04. | Chipana Catalán, Jhoel Williams. | RNA – OSCE |

**24.** En consecuencia, y en virtud del principio Kompetenz – Kompetenz, *el Árbitro de Emergencia declara su competencia para conocer la solicitud de medida de emergencia presentada por el Consorcio Doce Corrales*, toda vez que se ha cumplido con el procedimiento establecido en las Reglas de Árbitro de Emergencia y de acuerdo con la normativa nacional aplicable.

## F.- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS CAUTELARES EN LA MEDIDA DE EMERGENCIA SOLICITADA POR EL CONSORCIO DOCE CORRALES.

**25.** Mediante el escrito de vistos (i), el Consorcio Doce Corrales, solicitó que se conceda en su favor medida cautelar de no innovar, según los siguientes términos:

> ***3. PRETENSIÓN CAUTELAR***
> *En ejercicio del derecho a la tutela cautelar, y en salvaguarda de los derechos e intereses del CONSORCIO DOCE CORRALES; al amparo de lo dispuesto en el artículo 687° del Código Procesal Civil, del inciso b) del artículo 63° del Reglamento de Arbitrare de Centro de Arbitraje - CECARD y el artículo 47° del Decretos Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 1071;* ***SOLICITAMOS DICTE MEDIDA CAUTELAR de NO INNOVAR CONSISTENTE EN: ORDENAR*** *al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO* ***SE ABSTENGA A EJECUTAR****:*
> *(i) La* ***CARTA FIANZA N° E0359-03-2021****, emitida por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, por el importe de S/. 767,455.80 (setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 80/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N° 008-2021-GRASEDE CENTRAL-OAPF; y sus futuras renovaciones.*
> *(ii) (ii) Solicitamos además que los efectos de la orden cautelar se extiendan a SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, con domicilio en la Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, Edificio "Real Diez", Ofic. 601 Centro Empresarial Real – Lima;* ***ORDENANDO*** *se*

*abstenga y/o rechace cualquier 3 requerimiento y/o solicitud por parte del GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO destinada a ejecutar La* ***CARTA FIANZA N° E0359-03-2021****.*

*En consecuencia, se curse comunicación al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, con domicilio en el Jr. Callao N° 122 – Ayacucho – Huamanga - Ayacucho; así como a SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS con sede en la Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, Edificio "Real Diez", Ofic. 601 Centro Empresarial Real – Lima.*

**26.** Como hemos hecho mención anteriormente, corresponde realizar el análisis de los tres presupuestos fundamentales para la dación de medidas cautelares (verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida). Adicionalmente, se evaluará el otorgamiento de la contracautela realizada por el Consorcio Doce Corrales, como requisito de las medidas cautelares, en atención a garantizar los eventuales daños que devengan de la misma si otorgada la medida de emergencia, no correspondiere la misma. Es decir, en atención a evitar al peligro de que la medida de emergencia se indebidamente otorgada, *toda vez que una medida de emergencia o cautelar siempre es otorgada bajo una probabilidad razonable pero nunca bajo certeza.*

**27.** En virtud de lo señalado, procedemos a realizar el análisis comprendiendo los medios probatorios ofrecidos por el solicitante y los argumentos desarrollados en el escrito de vistos.

**F.1.- Configuración de la verosimilitud en el derecho.**

**28.** La verosimilitud en el derecho no implica la mera probabilidad que el derecho corresponda al solicitante, sino, la existencia de una *probabilidad razonable*[3] del mismo. Ello quiere decir que el derecho alegado debe ser acompañado de los medios probatorios *pertinentes y suficientes* para crear la convicción, al grado de verosimilitud, en el Tribunal Arbitral. Empero, debe hacerse la salvedad que la verosimilitud del derecho no exige comprobación de certeza, sino solamente de humo de derecho, esto es, de probabilidad[4]. *No siendo admisible, que se impugne una decisión que otorgue una medida cautelar por no existir convicción plena en la correspondencia del derecho, asimismo, como deducir que la dación de una medida cautelar implique un pronunciamiento anticipado sobre el fondo de la controversia.*

**29.** En virtud del Contrato N°008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-O-APF el Consorcio Doce Corrales otorgó como Garantía de Fiel Cumplimiento la Carta Fianza N° E0359-03-2021 por la suma de S/767,455.80 (Setecientos Sesenta y Siete Mil

[3] Monroy Palacios, J. (2002). *Bases para la Formación de una Teoría Cautelar*. Lima: Communitas

[4] Martel Chang, R. (2003). *Tutela Cautelar y Medidas Autosatisfactivas en el Proceso Civil*. Lima: Palestra Editores.

Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 80/100 Soles), misma que se encuentra vigente a la fecha de emisión de la presente Resolución:

SECREX CESCE
El valor del crédito

Confirme y/o certifique esta garantía al instante mediante la lectura de nuestro código QR

CARTA FIANZA
N° E0359-03-2021

De nuestra consideración:
Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO * * *

**32.** Ahora bien, el Gobierno Regional de Ayacucho comunicó al contratista el cumplimiento de obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato a través de la Carta Notarial N°289-2022-GRA/GR-GG, de fecha 22 de noviembre de 2022, en los términos que siguen:

> Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), a través del cual, se informa los reiterativos retrasos injustificados de obra, incumplimiento de la permanencia del personal clave en obra, no correcciones a las observaciones y no conformidades comunicadas por la supervisión de la obra y situaciones adversas informadas por el órgano de control sobre la ejecución de la "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP.AY.647 (TRANCA) - AY - 646 (SAYHUA-DOCECORRALES), DEL DISTRITO DE SORAS Y SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO", con CUI N° 2489948; no obstante, haberles emplazado con documento de la referencia b), de fecha 30 de setiembre de 2022, el riesgo de incumplimiento contractual; por lo que, **se requiere el cumplimiento de sus obligaciones contractuales**, debiendo en un plazo de cinco (5) días calendarios informar las acciones implementadas y a implementar de manera sustentada, a fin de revertir las situaciones anteriormente expuestas, **bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio que se adopten las acciones conforme a ley, en salvaguarda de los intereses del estado.**
>
> Aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientos de estima personal.
>
> Atentamente,
>
> GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**33.** De las consideraciones expuestas en el referido documento, se puede advertir que la Entidad alega los siguientes incumplimientos de parte del Consorcio Doce Corrales: (i) Reiterativos retrasos injustificados de obra; (ii) Incumplimiento de la permanencia del personal clave en obra; (iii) No correcciones a las observaciones y no conformidades de la supervisión; y, (iv) Situaciones adversas comunicadas por el Órgano de Control.

**34.** En ese sentido, para efectos de requerir el cumplimiento de las obligaciones de parte del Consorcio Doce Corrales se concedió el plazo de cinco (05) días hábiles para la ejecución de las mismas, bajo apercibimiento de resolver el contrato sub litis.

**35.** Bajo la misma línea argumentativa, a través de la Carta Notarial N°296-2022-GRA/GR-GG de fecha 06 de diciembre de 2022, la Entidad comunica al contratista su decisión de resolver el contrato por un supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales, según se puede apreciar de la citada Carta:

Ver en la página siguiente…

> Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a) y manifestar que el Gobierno Regional de Ayacucho, ha comunicado a su representada reiterados incumplimientos contractuales como la no permanencia del personal clave en obra, no correcciones a las observaciones y no conformidades comunicadas por la supervisión de la obra y situaciones adversas informadas por el órgano de control sobre la ejecución de la obra "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP.AY.647 (TRANCA) - AY - 646 (SAYHUA-DOCECORRALES), DEL DISTRITO DE SORAS Y SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO", con CUI N° 2489948, ante lo cual, **su representada ha incumplido injustificadamente sus obligaciones contractuales**, pese a haber sido requerido para ello, con documento de la referencia b), y habiendo otorgado un plazo de cinco (5) días calendarios, a fin que sustente las acciones implementadas y a implementar; en tal sentido, y en amparo de lo establecido artículo 92 del Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM de fecha 6 de julio de 2018, con el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado con Decreto Supremo Nº 148-2019-PCM de fecha 22 de agosto de 2019, **RESOLVEMOS DE FORMA TOTAL EL CONTRATO N° 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF** de fecha 17 de febrero de 2021, por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales sobre la ejecución de la obra "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP.AY.647 (TRANCA) - AY - 646 (SAYHUA-DOCECORRALES), DEL DISTRITO DE SORAS Y SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO", con CUI N° 2489948.

**36.** Del contenido de la Carta Notarial N°296-2022-GRA/GR-GG se aprecia que las obligaciones incumplidas de parte del Consorcio Doce Corrales, serían las siguientes: (i) No permanencia del personal clave en obra; (ii) No correcciones a las observaciones y no conformidades de la supervisión; y, (iii) Situaciones adversas informadas por el Órgano de Control.

**37.** Adviértase que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) ha señalado con la Opinión N°083-2021/DTN, que, en el procedimiento de resolución contractual, la segunda carta que comunica la resolución contractual debe versar respecto de los mismos incumplimientos comunicados con la carta que informa sobre el apercibimiento de resolución contractual, según se lee:

> *En ese sentido, si la Entidad le atribuye al contratista la falta de cumplimiento de sus obligaciones –sean éstas contractuales, legales o reglamentarias-, mediante una primera carta notarial, esta debe requerirle que las ejecute, bajo apercibimiento de resolver el contrato, para lo cual le otorgará el plazo que estime pertinente según lo previsto en el artículo 165 del Reglamento; así, en caso venciera el plazo otorgado y la misma situación de incumplimiento continuara –es decir, que el contratista no haya ejecutado las obligaciones cuya falta motivaron el requerimiento cursado a través de la primera carta notarial-, la Entidad puede decidir resolver el contrato, notificando dicha decisión a través de una segunda carta notarial.*

**38.** Ahora bien, como se puede apreciar de los actuados, la Entidad considera en un primer momento el retraso injustificado como un incumplimiento de obligaciones como causal de resolución de contrato, empero, con la Carta Notarial N°296-2022-GRA/GR-GG, no ha señalado la misma como un incumplimiento, por lo

que, permite entrever al Árbitro de Emergencia un posible cumplimiento respecto de estas obligaciones o, en todo caso, el desistimiento del Gobierno Regional de Ayacucho sobre este posible incumplimiento.

**39.** Asimismo, se deja constancia que, a través de la solicitud de arbitraje de emergencia y las posibles pretensiones a someter a arbitraje, el contratista ha formulado sus argumentos para cuestionar la resolución contractual realizada por la Entidad en los términos siguientes:

| **PRONUNCIAMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RETRASO INJUSTIFICADO** | **AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA** | **FALTA DE ABSOLUCIÓN A OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN** | **SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS POR EL OCI** |
| El retraso injustificado se encuentra determinado por la Entidad a través de una suposición que sea menor al 80% de ejecución de la misma, es decir, este no se encuentra debidamente corroborado por la Entidad. Asimismo, el numeral 5 del artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indica que el retraso debe ser inequívocamente menor al 80% del avance proyectado para su ejecución. | Este causal tenía la consecuencia de penalidad, más no como causa de resolución contractual, según la penalidad por “otras penalidades” contemplada en el ítem 4 de la Cláusula Sexta del Contrato. | Sobre el particular, correspondía que las observaciones y situaciones adversas comunicadas durante la ejecución de la obra sean debidamente identificadas a efectos que estas puedan ser absueltas por el contratista, de conformidad con lo señalado en la Opinión N°083-2021/DTN emitida por el OSCE. | |

**40.** Bajo esa línea de análisis, se procede a exponer las consideraciones del Árbitro de Emergencia para efectos de la verosimilitud en el derecho de la medida cautelar solicitada por el Consorcio Doce Corrales, en el sentido que se desarrolla a continuación:

- **<u>Respecto del retraso injustificado alegado por la Entidad</u>:** Se advierte que el retraso invocado por la Entidad se debería a que la obra se encontraría en un retraso por debajo del 80% acumulado programado al 30 de noviembre de 2022, empero, del Informe N°0334-2022-GRA/GG-GRI-SGSL-JAFM, de fecha 15 de noviembre de 2022, la Entidad no ha verificado de forma fehaciente este retraso, estando a un grado de probabilidad, más no, convicción, según se lee:

> **4. <u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.</u>**
>
> 4.1. Por lo expuesto en el Punto N°03, se concluye que el Ing. Supervisor Hermes Ricalde Tinoco cumple con la presentación oportuna del informe especial solicitado respecto al cumplimiento de los acuerdos por parte del Contratista CONSORCIO DOCE CORRALES; sin embargo, se evidencia el incumplimiento de estos acuerdos por el mismo, razón por la cual se hace necesario notificar notarialmente al contratista a través del área correspondiente, que realice el cumplimiento de su contrato conforme a la CLÁUSULA TERCERA: OBJETO, sustentando técnicamente de qué manera superará los retrasos injustificados a la fecha de culminación de obra vigente y si de no emitir respuesta en un plazo de 5 días calendarios o de ser negativa frente a lo solicitado, se tomarán la presente como una prueba más que suficiente <u>para sustentar una posible resolución de contrato si se vuelve a presentar un retraso por debajo del 80% acumulado programado al 30/11/2022.</u>
>
> 4.2. Se recomienda derivar la presente a la Gerencia Regional de Infraestructura, para las acciones

Por tales consideraciones, se puede advertir que la controversia sobre este supuesto incumplimiento contractual deberá ser determinada por un Tribunal Arbitral a efectos de advertir si corresponde o no la resolución contractual por dicha causa.

- **<u>Respecto de la ausencia del personal clave en la obra</u>:** En el mismo sentido, se puede advertir que el ítem 4 de otras penalidades contemplado en la Cláusula Décima Sexta del Contrato Sub Litis contempla como supuesto de penalidad la ausencia del personal clave en obra, según los términos siguientes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Reglamento. | | |
| 4 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda. |
| | | 0.5 UIT vigente en la oportunidad que se | Según informe del |

A su vez, la misma cláusula contractual invocada, señala que la aplicación de penalidades será causal de resolución contractual cuando estas acumulen el monto máximo de penalidad de forma independiente, pudiendo configurarse como supuesto de resolución contractual en esos casos, según se lee:

Ver en la página siguiente…

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
OFICINA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

018

Adicionalmente a ello, este Árbitro de Emergencia advierte que, al tratarse de un supuesto de otras penalidades estas no son de aplicación automática como la penalidad por mora, por lo que se deberá discutir la aplicación de penalidades o resolución contractual según los supuestos legales que correspondan.

En ese sentido, al encontrarse en controversia esta causal, deberá ser discutida ante el Tribunal Arbitral que resulte competente.

- **Falta de absolución a observaciones de la Supervisión y del Órgano de Control Interno[5]:** Ahora bien, sobre el último punto se indica que las observaciones comunicadas por la supervisión así como las situaciones adversas que advirtiese el OCI en su momento, debieron ser debidamente determinadas a efectos que estas puedan subsanarse por parte del Consorcio Doce Corrales; situación que deberá ser determinada con el rigor técnico que amerita el análisis del Tribunal Arbitral en caso de ejecución de obra.

**41.** Bajo esta línea argumentativa, se puede advertir que la resolución contractual efectuada por el Gobierno Regional de Ayacucho tiene cuestionamientos razonables que permiten que el Árbitro de Emergencia considere verosímil la posible pretensión planteada por el Consorcio Doce Corrales.

**42.** Máxime, si, adicionalmente a ello, se cuenta con la resolución contractual que efectuara en su oportunidad el mismo Consorcio Doce Corrales al Gobierno Regional de Ayacucho por incumplimiento de obligaciones derivado de valorizaciones impagas, según se puede advertir:

[5] Se precisa que el análisis de estas causales se realiza en conjunto de parte del Árbitro de Emergencia en tanto a que el contratista ha procedido a absolver las mismas en ese sentido.

**REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES**
**(CARTA NOTARIAL S/N DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022)**

DOCUMENTO NO REDACTADO
NOTARIO MARIO ALMONACID CISNEROS

0091

NOTARIA ALMONACID
01 DIC 2022
RECIBIDO
Hora: 4:00 Firma:

Ayacucho, 01 de diciembre de 2022.

**CARTA NOTARIAL**

**SR. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**

**ASUNTO** : Solicito cumpla con su obligación esencial, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

**REFERENCIA** : Contrato N° 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF

CONSORCIO DOCE CORRALES (Conformado por MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. y MIFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L.), con domicilio en el Jr. Scarsi N° 224, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga – Ayacucho, debidamente representado por Vladimir Herber Oriundo Ochoa, identificado con DNI Nro. 28314310; ante usted, respetuosamente nos presentamos y decimos:

Que, en mérito a lo referido en el art. 63° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de requerirles para que, en un plazo no mayor de 3 días, cumpla con las siguientes obligaciones esenciales:

1. Cumpla con su obligación esencial de pago de valorización
2. Cumpla con disponer nuevas canteras para la extracción del material tipo afirmado
3. Cumpla Obligación esencial de reestablecer el equilibrio económico

Continúa en la siguiente página

**RESOLUCIÓN DE CONTRATO**
**(CARTA N°100-2022/CD-RC DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022)**

NOTARIO MARIO ALMONACID CISNEROS

0093

CONSORCIO DOCECORRALES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CARTA N° 100- 2022/CD-RC

NOTARIA ALMONACID
Dr. Mario Almonacid C.
06 DIC 2022
RECIBIDO

SEÑORES:
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Jr. Callao N° 122 – Ciudad de Ayacucho

Atención : ING. WHILHEM ORE CHIPANA
GERENTE REGIONAL DE AYACUCHO

Asunto : RESOLVEMOS CONTRATO N° 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF

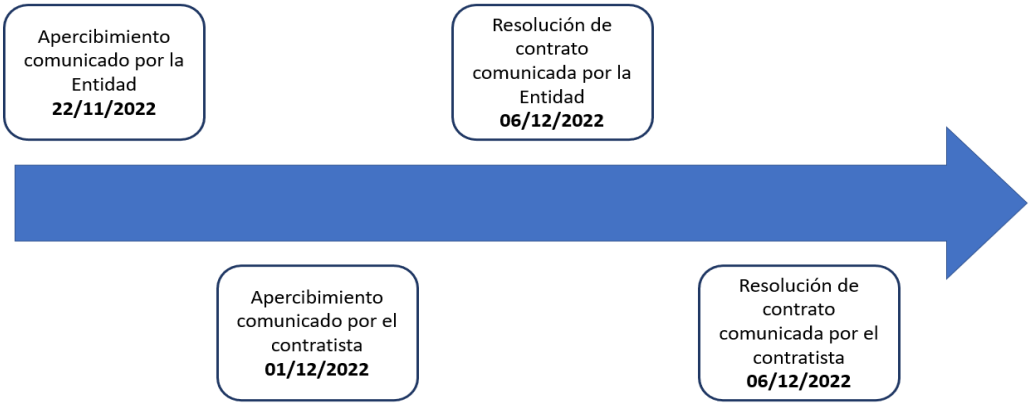
Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL – 34.5 KM EMP. AY-647 (TRANCA) – AY-646 (SAYHUA-DOCECORRALES) DISTRITO DE SORAS Y SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO".

Referencia : Carta Notarial entregada el 01 de diciembre de 2022, mediante el cual solicitamos cumplimiento de obligación esencial, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SECRETARIA GENERAL
ÁREA TRAMITE DOCUMENTARIO

Fecha : Ayacucho, 06 de Diciembre de 2022.

**43.** En ese sentido, según se puede advertir de los medios de prueba documentales que obran en el expediente arbitral de emergencia, las resoluciones contractuales se ordenan de la manera siguiente:




**44.** Como se puede apreciar, en el caso de autos existen dos resoluciones de contrato mutuamente entre las partes procesales, lo cual, de conformidad con la Opinión N°086-2018/DTN[6] emitida por el OSCE, resultaría en un imposible

[6] La OPINIÓN N°086-2018/DTN señala lo que sigue: *En virtud de lo expuesto, puede colegirse que si una de las partes (Entidad o contratista) resuelve debidamente un contrato –es decir, siguiendo el procedimiento y cumpliendo los requisitos y formalidades previstas en la normativa de contrataciones del Estado- no cabría la posibilidad de que su contraparte efectué una nueva resolución respecto del mismo contrato, puesto que, para entonces, la relación jurídica ya se encontraría extinta*.

jurídico toda vez que la resolución contractual se efectúa de pleno derecho una vez comunicada esta.

**45.** Por lo tanto, resulta urgente que un Tribunal Arbitral determine la validez y eficacia de alguna de las resoluciones contractuales en el presente caso, con la finalidad de determinar cuáles son los efectos legales que corresponden de conformidad a la normativa de contrataciones del Estado y, en especial, al Decreto Supremo N°071-2018-EF.

**46.** Con mayor razón aún, si ninguna de las dos resoluciones, a la fecha han quedado consentidas, siempre que aún se encuentra en transcurso el plazo de treinta (30) días hábiles que contempla el último párrafo del artículo 92° del citado decreto supremo, según se puede leer:

> ***Artículo 92.- Resolución del contrato de obras***
> *(…)*
> *En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en el Reglamento, la Ley de Contrataciones, el Reglamento de la Ley de Contrataciones o en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida.*

**47.** Ahora bien, considerando que ambas resoluciones de contrato fueron comunicadas el 06 de diciembre de 2022, el plazo para que las mismas queden consentidas sería hasta el día 24 de enero de 2023, según se aprecia del cálculo realizado con la calculadora del Gobierno del Perú[7]:

En **30** días hábiles a partir de **mar, 06 dic 2022**, será:

**martes 24 de enero de 2023**

Volver a calcular

**48.** En consecuencia, no se configuraría el supuesto de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, siempre que esta requiere que exista una resolución debidamente consentida, según se lee del citado literal b), del numeral 2 del artículo 61° del Decreto Supremo N°071-2018-EF, según se aprecia:

> ***Artículo 61°. - Otras Garantías y ejecución***
> *(…)*
> *61.2 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:*
> *(…)*

[7] Disponible en: https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario.

> *b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.*

**49.** En ese sentido, al existir un alto grado de controversia entre la validez y eficacia de la resolución de contrato efectuada por el Gobierno Regional de Ayacucho, corresponde indicar que existiría la imposibilidad de ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento al no existir una resolución contractual debidamente consentida como lo exige el literal b), del inciso 2, del artículo 61° del Decreto Supremo N°071-2018-EF.

**50.** Por las consideraciones expuestas, el Árbitro de Emergencia estima configurada la verosimilitud en el derecho invocado por el Consorcio Doce Corrales, respecto de la resolución contractual efectuada por el Gobierno Regional de Ayacucho, existiendo elementos fundados que generan verosimilitud.

**F.2.- Configuración del peligro en la demora.**

**51.** *El peligro en la demora implica que de no emitirse la medida de emergencia solicitada puede ponerse en peligro la eficacia material de la decisión final del proceso*. Para Piero Calamandrei el peligro en la demora es el interés específico que justifica la emanación de cualquiera de las medidas cautelares. El peligro en la demora configura el interés para obrar necesario para obtener del órgano jurisdiccional el dictado de una medida cautelar[8].

**52.** El fundamento del peligro en la demora se ubica en el principio del Derecho Procesal que versa de la siguiente manera: *El proceso no debe dañar a quien le corresponde el derecho*. Para la configuración del peligro en la demora no se necesita evidenciar la posibilidad o la existencia de actos dilatorios por alguna de las partes, sino la inminencia que por el solo paso del tiempo que dure el proceso se pueda generar un daño a quien le corresponde el derecho, mismo que puede ser: i) deviniendo en inejecutable la decisión final (Laudo Arbitral), o, ii) que pueda generarse un daño irreversible al solicitante.

**53.** En ese sentido, el Árbitro de Emergencia considera pertinente ampararse en el segundo supuesto, es decir, que de no otorgarse la medida cautelar *podría generarse un daño irreversible al solicitante, toda vez que de ejecutarse la Carta Fianza se generaría un perjuicio económico al contratista y una afectación directa al Equilibrio Económico Financiero del mismo*, toda vez que ante la situación actual de la crisis de carácter económico generalizado, a causa de la

[8] Priori Posada, G (2005). La tutela cautelar: su configuración como derecho fundamental. En *Ius Et Veritas*, 15 (30), 171 – 200.

pandemia mundial, una decisión de este carácter puede ser perjudicial para el restablecimiento económico de cualquier persona (natural o jurídica) dedicada al ejercicio empresarial.

**54.** Al respecto se debe considerar que el sistema de contrataciones del Estado peruano contempla la ejecución de garantías como un procedimiento expeditivo y célere, según se advierte del numeral 2, del artículo 33° de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual regula lo que sigue:

> *33.2 Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.*

**55.** Por tanto, el Consorcio Doce Corrales ha acreditado de forma fehaciente el peligro en la demora, siempre que ha acreditado el pedido expreso del Gobierno Regional de Ayacucho a la empresa aseguradora para la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento a través de las siguientes comunicaciones:

**<u>CARTA NOTARIAL N°104-2022-GRA/GG-ORADM DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022</u>**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Jr. Callao Nº 122 - 3er. Piso - Ayacucho
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

NOTARIA HINOSTROZA AUCASUNE
07 DIC 2022
RECIBIDO
Hora Firma

Ayacucho, 07 DIC 2022

CARTA NOTARIAL N° 104 -2022-GRA/GG-ORADM.

SEÑORES:
SECREX CESCE.
AV. Víctor Andrés Belaunde Nº 147, Edif "Real Diez", Ofic. 601 Centro Empresarial Real – Lima 27 Perú – San Isidro.

LIMA.-

ASUNTO : Ejecución de Carta Fianza.

REF. : Carta Fianza N° E2167-00-2022.

Es grato dirigirme a ustedes para comunicarle que en marco de lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y modificaciones que contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las entidades del sector público en los procesos de contratación de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que derivan de los mismos, entre los cuales se encuentra relacionado a las garantías que deben otorgar los contratistas y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898° del Código Civil en los términos y condiciones siguientes:

**CARTA NOTARIAL N°117-2022-GRA/GG-ORADM DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE TESORERIA

"Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional"

CARTA NOTARIAL Nº 3878-20
JOSE HINOSTROZA AUCAS
ABOGADO - NOTARIO PÚBLICO DE AYAC
REG. C.A.A. Nº 606 - REG. C.N.A. Nº

Ayacucho, 20 DIC 2022

CARTA NOTARIAL N° 117 -2022-GRA/GG-ORADM

SECREX CESCE.
AV. Víctor Andrés Belaunde Nº 147, Edif. "Real Diez", Ofic. 601 Centro Empresarial Real – Lima 27 Perú – San Isidro.
Departamento de Cartas Fianza
LIMA.-

ASUNTO : Ampliación de la ejecución de carta fianza N° E00359-03-2021

REF. :a).- CARTA NOTARIAL N° 104-2022-GRA/GG-ORADM.
b).-OFICIO N° 4528-2022-GRA-GGR/GRI-SGSL.
c).- CARTA NOTARIAL N° 296-2022-GRA/GR-GG

NOTARIA HINOSTROZA AUCASIME
20 DIC 2022
RECIBIDO

Por el presente le comunico a usted, que el Gobierno Regional de Ayacucho ha presentado a su entidad financiera para la ejecución de la Carta Fianza N° E0359-02-2021, por el importe de S/ 767,455.80, con vencimiento al 06.12.2022, del contratista **CONSORCIO DOCECORRALES : MINKA S.A.C. CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOACIEDAD ANONIMA CERRADA- MINKA S.A.C MIFER OBRAS CIVILES GENERALES E.I.R.L**, en vista que de acuerdo a los documentos

**56.** Por estas consideraciones, el Árbitro de Emergencia, considera que existe un peligro actual e inminente sobre la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento cuando no se ha discutido en un arbitraje, ni se cuenta con Laudo Arbitral firme, sobre la resolución del contrato efectuada por el Gobierno Regional de Ayacucho.

**F.3.- <u>Configuración de la adecuación de la medida</u>.**

**57.** En el ordenamiento jurídico peruano existen cuatro tipos de medidas cautelares: **i)** Innovativas; **ii)** De No Innovar; **iii)** Temporales sobre el fondo; y, **iv)** De Ejecución Forzada. Cada una de ellas está enfocada a la tutela de los derechos del solicitante, aunque en distintas situaciones y con diversas finalidades:

- **Medidas Innovativas:** Tienen la finalidad de cambiar la situación de hecho en la que se encuentran las partes respecto de la controversia a efectos de eliminar, suspender o reestablecer las circunstancias con anterioridad al perjuicio generado.

- **Medidas de No Innovar:** Buscan mantener la situación de hecho en el estado en que se encuentran a efectos de evitar que se genere un daño hasta la emisión de la decisión final del proceso arbitral.

- **Medidas temporales sobre el fondo:** Tienen como objeto adelantar los efectos de la decisión final en cuanto permiten asegurar la eficacia del Laudo Arbitral.

- **Medidas de ejecución forzada:** Su finalidad es la de guardar una garantía destinada a asegurar la ejecución forzada de bienes muebles o inmuebles.

**58.** El desarrollo de la razonabilidad o la adecuación de la medida implica el desarrollo del test de proporcionalidad compuesto por sus tres subprincipios:

- **Idoneidad:** Consiste en que la medida solicitada se óptima para conseguir los fines pretendidos, es decir, si se quiere usar términos de teoría probatoria, la medida debe ser conducente a los fines perseguidos por el Solicitante.

- **Necesidad:** Asimismo, la aplicación de la medida específica debe ser necesaria, es decir que no exista otra forma de tutelar el derecho del solicitante.

- **Proporcionalidad propiamente dicha:** Por último, la medida idónea y necesaria debe ser la menos lesiva para los derechos del Solicitante, es decir, los derechos restringidos deben ser proporcionales al derecho tutelado.

**59.** Asimismo, la medida cautelar solicita deberá ser suficiente para cumplir la finalidad del petitorio, es la medida menos gravosa para quien soporta la medida cautelar y si la tutela del derecho del solicitante se encuentra con proporción a los derechos restringidos al Gobierno Regional de Ayacucho:

**A)** **Idoneidad:** Debe anotarse, nuevamente, que lo que se ha solicitado es una *medida cautelar de no innovar*, misma que, como hemos señalado, sirve para mantener el estado de las cosas como se encuentran a efectos de evitar que se genere un daño al solicitante. Así pues, habiéndose señalado la evidente intención del Gobierno Regional de Ayacucho para ejecutar las garantías referidas, requiriendo a la empresa aseguradora; y, no habiéndose ejecutado la garantía hasta la fecha, *esta medida implicaría que se mantenga este estado de cosas hasta la emisión de un Laudo Arbitral al respecto*. En consecuencia, la medida solicitada resulta idónea.

**B)** **Necesidad:** Por otro lado, debe hacerse hincapié que la medida solicitada es necesaria, toda vez que existiendo un inminente peligro (Carta Notarial N°104-2022-GRA/GG-ORADM de fecha 07 de diciembre de 2022 y Carta Notarial N°117-2022-GRA/GG-ORADM de fecha 20 de diciembre de 2022) de ejecutar las garantías por requerimiento a la empresa SECREX CESCE, *hasta dilucidarse las controversias con el Laudo Arbitral, es mediante una medida cautelar que sea idónea, es decir, una medida cautelar de no innovar.*

C) **<u>Proporcionalidad propiamente dicha</u>:** Por último, debe declararse que la medida solicitada es la menos gravosa y la más efectiva para tutelar el derecho del solicitante, según los siguientes términos: **a)** No correspondería una medida innovativa porque lo que se busca es mantener el estado de las cosas (es decir, la no ejecución de las cartas fianzas, en virtud del contrato); **b)** Tampoco puede ser de aplicación una medida temporal sobre el fondo, porque esta controversia aún no ha sido llevada a un Tribunal Arbitral y no corresponde al Árbitro de Emergencia pronunciarse sobre el fondo; y, **c)** Finalmente, no corresponde una medida de futura ejecución forzada porque las pretensiones esbozadas en la Solicitud de Medida de Emergencia no tienen esta naturaleza jurídica.

**60.** A estas consideraciones se debe añadir que el Gobierno Regional de Ayacucho no se estaría perjudicando económicamente, toda vez que el Consorcio Doce Corrales tiene la obligación legal de mantener la vigencia de la carta fianza otorgada a manera de garantía de fiel cumplimiento, según se lee del numeral 2 del artículo 60° del Decreto Supremo N°071-2018-EF, según se lee:

> *60.2 Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.*

**61.** Adicionalmente a ello el Árbitro de Emergencia dispondrá el cumplimiento de la contracautela de conformidad a la normatividad vigente, así como incluir en la orden de medida cautelar de emergencia mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de conformidad con la normatividad aplicable al fondo de la controversia.

**62.** Por estas consideraciones, el Árbitro de Emergencia, considera adecuada la medida cautelar de emergencia dictada al Gobierno Regional de Ayacucho en los términos indicados.

## <u>G.- RESPECTO DE LA CONTRACAUTELA EN LA MEDIDA DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA</u>.

**63.** La contracautela es la <u>*garantía que extiende el solicitante en favor de quien soportará la medida cautelar a efectos de cubrir los daños que, eventualmente, origine la indebida aplicación de la medida cautelar*</u>, es decir, tiene la finalidad, en principio, asegurar el resarcimiento de daños al demandado por el anticipo de tutela a favor del demandante.

**64.** El otorgamiento de la contracautela se justifica debido a que una medida cautelar siempre se fundamenta en una probabilidad, más no en una certeza, por lo que siempre existe la posibilidad que esta haya sido otorgada quien no le correspondiere el derecho. Considerando, que una medida cautelar siempre implica la restricción de derechos, la contracautela, busca proteger o resarcir los daños generados por una medida cautelar aplicada de forma indebida.

**65.** En ese sentido, en el párrafo in fine del numeral 2, del artículo 8° de la Ley de Arbitraje modificado por el Decreto de Urgencia N°020-2020, se ha regulado el tipo de contracautela a ofrecer en los arbitrajes en los que participa el Estado como sujeto pasivo de la medida cautelar, según los términos siguientes:

> ***Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.***
> *2. (...)*
> *En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral. El monto de la contracautela lo establece el/ la juez/a o el tribunal arbitral ante quien se solicita la medida cautelar, dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. La ejecución de la carta fianza se establece conforme a lo resuelto por el/la juez/a o el tribunal arbitral, según corresponda.*

**66.** Considerando que el Gobierno Regional de Ayacucho forma parte del Estado, en tanto gobierno local, corresponde aplicar de forma directa lo regulado por el Decreto de Urgencia N°020-2020 en tanto a que se otorgue la carta fianza indicada anteriormente y según lo dispuesto en la presente Resolución.

Por las consideraciones expuestas, el Árbitro de Emergencia **RESUELVE:**

**PRIMERO: TENER POR CUMPLIDO** el pago de Honorarios Arbitrales y Gastos Administrativos que corresponden al **CONSORCIO DOCE CORRALES**.

**SEGUNDO: DEJAR CONSTANCIA** que el **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO** no ha remitido escrito alguno respecto de su postura sobre la medida cautelar solicitada por el **CONSORCIO DOCE CORRALES**.

**TERCERO: PRESCINDIR** de la realización de audiencia especial a la que refiere el quinto artículo resolutivo de la Resolución de Arbitraje de Emergencia N°01, siempre que no se estima pertinente al no contar con contradicción de parte del **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**.

**CUARTO:** Declarar **FUNDADO** el pedido de medida cautelar de emergencia formulado por el **CONSORCIO DOCE CORRALES**, en consecuencia, **DICTAR MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR** contra el **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO** consistente en que **SE ABSTENGA DE EJECUTAR** la **CARTA FIANZA N° E0359-03-2021**, emitida por **SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS**, por el importe de **S/.767,455.80 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL**

**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/100 SOLES)** que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N°008-2021-GRASEDE CENTRAL-OAPF; así como sus futuras renovaciones. **PRECISAR** que la medida cautelar de emergencia de no innovar, dispuesta en el presente artículo resolutivo, se mantenga vigente hasta la emisión del Laudo Final que resuelva las controversias entre las partes, derivadas del Contrato N°008-2021-GRASEDE CENTRAL-OAPF.

**QUINTO: OFICIAR** a la empresa **SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS** con la presente resolución a efectos que tome conocimiento de la medida cautelar de emergencia dictada por el Árbitro de Emergencia y **SE ABSTENGA** de realizar cualquier actuación destinada a la ejecución de la **CARTA FIANZA N° E0359-03-2021**, emitida por **SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS**, por el importe de **S/.767,455.80 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/100 SOLES)** que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N°008-2021-GRASEDE CENTRAL-OAPF.

**SEXTO: ORDENAR** al **CONSORCIO DOCE CORRALES**, presentar **CONTRACAUTELA** por la suma fijada en la cantidad de **S/.767,455.80 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/100 SOLES)** de conformidad con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N°020-2020; dentro del **PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES**, computados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de revocar la medida cautelar de emergencia otorgada.

**SÉPTIMO: PRECISAR** que una vez presentada la contracautela indicada esta quedará en custodia de la institución arbitral Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD hasta la emisión del Laudo Final que resolverá las controversias derivadas del Contrato N°008-2021-GRASEDE CENTRAL-OAPF. A su vez, será puesta en conocimiento del **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO** y del Árbitro de Emergencia, a efectos de dar cuenta del cumplimiento de este mandato.

**OCTAVO: ORDENAR** al **CONSORCIO DOCE CORRALES**, mantener vigente la **CARTA FIANZA N°E0359-03-2021 DE FIEL CUMPLIMIENTO**, de conformidad con la normatividad aplicable al fondo de la controversia, hasta la emisión del Laudo Final que resolverá las controversias derivadas del Contrato N°008-2021-GRASEDE CENTRAL-OAPF.

**NOVENO: ORDENAR** al **CONSORCIO DOCE CORRALES** que, en el **PLAZO PERENTORIO DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con presentar la respectiva Solicitud de Arbitraje correspondiente a resolver las controversias sobre la resolución del Contrato N°008-2021-GRASEDE CENTRAL-OAPF, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la medida cautelar de emergencia dictada en la presente resolución; de conformidad al artículo 4° de las Reglas de Árbitro de Emergencia del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.

**DÉCIMO: PRECISAR** que la presente resolución no amerita un análisis definitivo sobre el fondo de la controversia materia de litis siempre que esta deberá ser discutida en el Tribunal Arbitral que resulte competente para dicha función.

**<u>DÉCIMO PRIMERO</u>: ENCARGAR** a la secretaría Arbitral la notificación de la presente resolución a las partes conforme lo establece el Reglamento del Centro.

La presente Resolución se emite con la revisión y aprobación del **ÁRBITRO DE EMERGENCIA**: CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SOLIS. –

**CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SOLIS**
**ÁRBITRO DE EMERGENCIA**